

1502592-61.2021.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cássio Henrique Dolce de Faria

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... na hipótese de condenação por tráfico, pena no piso, com reconhecimento do tráfico privilegiado, concessão de regime aberto e substituição da sanção corporal. Na sequência, o MM. Juiz proferiu a sentença nos seguintes termos: "Vistos, etc. BRYAN WILLIAN IZIDORO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Jd. Panambi, Santa Bárbara d'Oeste - 13450-515 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502592-61.2021.8.26.0533

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2245512/2021 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 20140283 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2245512 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRYAN WILLIAN IZIDORO

Vítima:

Saúde Pública

Réu Preso

Aos 13 de janeiro de 2022, às 13:30h, em audiência realizada por videoconferência pela 2ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste, Comarca de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. CASSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA, comigo, escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual o representante do Ministério Público Dr. Rodrigo Aparecido Tiago, o acusado e o defensor Dr. James Marcio de Freitas Faria OAB 402136/SP, todos devidamente intimados e após responderem de forma positiva ao convite enviado pelo programa Microsoft Teams. Em seguida, foi concedida entrevista privada entre o acusado e seu advogado por meio da "sala virtual", com a garantia do sigilo da comunicação, permanecendo os demais em espera. Após a entrevista, houve o retorno deste servidor-organizador, do Magistrado e do representante do Ministério Público à audiência virtual. Como primeiro ato, todos os integrantes exibiram documento de identificação pessoal com foto. Iniciados os trabalhos, pela ordem, pelo defensor do acusado foi solicitado novo direito de entrevista privada com o réu após a colheita da prova testemunhal, o que foi deferido pelo MM. Juiz. Depois, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos, etc. 1) Tendo em vista o disposto no Decreto n.º 8.858/16 e na Súmula Vinculante n.º 11, do Supremo Tribunal Federal, justifico que houve manutenção das algemas para a garantia da integridade física de todos os

participantes da audiência, principalmente das pessoas que se encontram na sala de videoconferências do centro de detenção provisória em questão, vez que a segurança daquele local é realizada por reduzido número de agentes. Nesse sentido: “a excepcionalidade do uso de algemas, consignada principalmente na Súmula Vinculante 11, do STF - que dispõe que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito - não obsta o seu emprego se demonstrados os riscos nela previstos” (STJ, RHC: 39729 SP 2013/0241579-3, relator ministro Moura Ribeiro, julgado em 3 de setembro de 2013).

2) Conforme decidido no H.C. n.º 127.900/STF, determino que o interrogatório do réu seja o último ato da instrução. 3) Esta audiência será realizada excepcionalmente por meio virtual, na forma do Comunicado C.G. n.º 284/2020, diante da pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do fórum local, sendo que as gravações serão vinculadas a este termo de audiência”. A seguir, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas e uma informante arroladas em comum pelas partes e uma testemunha arrolada exclusivamente pela defesa, conforme gravações de áudio e vídeo realizadas através do programa Microsoft Teams, que serão vinculadas a este termo de audiência. Encerrada a colheita da prova testemunhal, pelo defensor do réu e pelo réu foi dito que dispensavam a realização de nova entrevista privada entre eles antes do início do interrogatório. Procedeu-se, então, ao interrogatório do réu, também conforme gravação de áudio e vídeo vinculada a este termo de audiência. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi dito: “Vistos, etc. Declaro encerrada a fase de instrução processual. Aos debates, de imediato”. Depois disso, passou-se aos debates orais em audiência, ainda conforme gravações de áudio e vídeo realizadas através do programa Microsoft Teams, que serão vinculadas a este termo de audiência, sendo que pelo Ministério Público, os principais pedidos foram: a procedência da pretensão inicial, com exasperação da pena-base em razão da quantidade e qualidade das drogas apreendidas, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, afastamento do tráfico privilegiado e fixação do regime inicial fechado para cumprimento da sanção corporal, com vedação à substituição e ao direito a recurso em liberdade e perdimento do dinheiro apreendido, enquanto que pela defesa, os principais pedidos foram: a absolvição, insistindo na nulidade de todo o processado, porque o flagrante decorreu de busca em domicílio sem mandado e desautorizada pela Constituição Federal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para uso ou, quando menos, na hipótese de condenação por tráfico, pena no piso, com reconhecimento do tráfico privilegiado, concessão de regime aberto e substituição da sanção corporal. Na sequência, o MM. Juiz proferiu a sentença nos seguintes termos: “Vistos, etc. BRYAN WILLIAN IZIDORO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. E isso porque, segundo consta da denúncia de fls. 1/3, no dia 9 de setembro de 2021, por volta de 15h15min, na Rua Jorge Juventino de Aguiar, n.º 190, bloco 190, apartamento 21-A, Conjunto Habitacional Roberto Romano, nesta cidade e comarca, ele trazia consigo e guardava, para fins de comercialização, 51 microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 38 gramas, 14 porções de crack, com peso aproximado de 10 gramas, 2 porções de maconha, pesando cerca de 5 gramas e 5 unidades de LSD, pesando aproximadamente 1 grama, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O acusado foi notificado (fls. 166) e apresentou defesa prévia (fls. 147/158). Recebida a denúncia (fls. 167/168), ele foi citado (fls. 205). Em audiência, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas e uma informante arroladas em comum e de uma testemunha arrolada somente pela defesa, interrogando-se o acusado, a seguir. Encerrada a instrução, em debates: a) o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão inicial, com exasperação da pena-base em razão da quantidade e qualidade das drogas apreendidas, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, afastamento do tráfico privilegiado e fixação do regime inicial fechado para cumprimento da sanção corporal, com vedação à substituição e ao direito a recurso em liberdade e perdimento do dinheiro apreendido; b) a defesa pediu a absolvição, insistindo na nulidade de todo o processado, porque o flagrante decorreu de busca em domicílio sem mandado e desautorizada pela Constituição

Federal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para uso ou, quando menos, na hipótese de condenação por tráfico, pena no piso, com reconhecimento do tráfico privilegiado, concessão de regime aberto e substituição da sanção corporal. É o relatório. Fundamento e decido. Não há matéria preliminar em sentido técnico pendente de apreciação. No mérito, a pretensão inicial procede em parte, pelos fundamentos expostos a seguir. A materialidade delitiva encontra-se provada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 13/18, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 22/23 e, finalmente, pelo laudo químico-toxicológico de fls. 120/122. Há, também, prova suficiente de autoria. Na polícia, o acusado negou a prática delitiva, afirmando que: a) na data dos fatos, estava com sua companheira Mariana no apartamento onde vivem; b) na ocasião foram surpreendidos por batidas na porta, a qual foi arrombada logo em seguida; c) policiais militares adentraram ao local, e ele foi abordado e retirado da presença de sua esposa; d) os agentes, sem exhibir mandado judicial, iniciaram as buscas em seu apartamento; e) ele foi mantido na sala e as buscas aconteceram nos quartos com as portas fechadas; f) uma vizinha se propôs a acompanhar o procedimento, mas não foi autorizada; g) os policiais localizaram em seu apartamento duas porções de maconha destinadas a uso e embalagens plásticas destinadas à manufatura de "geladinhos"; h) não são de sua propriedade os demais entorpecentes apreendidos, cuja procedência desconhece (fls. 12). Em juízo, ele ratificou essa versão, apenas acrescentando o nome da vizinha que não teria sido autorizada a acompanhar a diligência (Valéria) e esclarecendo que não havia embalagens plásticas destinadas à manufatura de "geladinhos" na sua casa, tendo lhe sido atribuída falsamente pelos policiais militares a propriedade deste objeto, bem como de todo o restante das drogas. Finalizou, dizendo que não conhecia os policiais militares anteriormente. Ocorre que a tese de autodefesa, para além de pouco crível, não encontra resguardo suficiente no cotejamento probatório. Senão vejamos. Pesam em desfavor do acusado: 1º) a situação comprometedora derivada de sua prisão em flagrante, trazendo consigo e guardando, em região conhecida como ponto de tráfico, para fins de comercialização, entorpecentes diversos, embalados individualmente e dinheiro; 2º) o relatado pelos policiais militares Walter e Gustavo, que confirmaram, na delegacia (fls. 7/8 e 10/11) e em juízo, em declarações complementares entre si, que: a) estavam em patrulhamento rotineiro pelo Conjunto Habitacional Roberto Romano (ponto conhecido de venda de drogas), no momento em que passavam pela Rua Jorge Juventino de Aguiar, imediações do Bloco 190, e se depararam com um indivíduo na prática aparente de tráfico de entorpecentes, carregando algo na mão e cercado de outros indivíduos; b) este indivíduo, posteriormente identificado como o réu, ao avistar a equipe policial, empreendeu fuga, motivo pelo qual passaram a acompanhá-lo; c) o réu, que trazia consigo uma pochete, adentrou correndo no prédio n.º 190, seguindo até o apartamento 21-A, onde entrou e trancou a porta; d) ao chegarem no referido apartamento, bateram na porta e puderam ouvir barulho de descarga de vaso sanitário, típica conduta de quem quer dispensar drogas; e) decidiram, então, arrombar a porta do imóvel e ingressar no local; f) no interior do apartamento se depararam com o indivíduo anteriormente perseguido, o qual foi abordado e submetido a busca pessoal; g) nada de ilícito foi encontrado com o acusado. Todavia, sobre a pia do banheiro de onde ele saiu, foi encontrada a pochete de cor preta; h) no interior da pochete havia 51 porções de cocaína, acondicionadas em pinos plásticos, 14 porções de crack, envoltas em papel alumínio, duas porções de maconha, cinco micropontos de LSD e R\$ 258,00 em dinheiro, entre cédulas e moedas; i) indagado, o réu negou que estivesse traficando; j) nas buscas pelo apartamento foram encontradas embalagens plásticas e fita adesiva, materiais comumente utilizados no acondicionamento de drogas fracionadas, além de quatro telefones celulares; k) na companhia de Bryan estava sua namorada, Mariana, a qual foi questionada e alegou desconhecer a procedência dos entorpecentes apreendidos, assim como negou ter conhecimento de que Bryan era envolvido com o tráfico de drogas; l) diante da situação, fizeram a detenção do casal. Não há motivo algum para que seja negada credibilidade aos relatos dos policiais militares, com quem o réu não demonstrou a existência de nenhuma animosidade. Depoimentos de policiais

harmônicos em sua essência e coerentes entre si e com o restante do conjunto probatório naquilo que importa são suficientes para fundamentar a sentença condenatória, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vide, a propósito, o decidido no Habeas Corpus n.º 395.325/SP, pela Quinta Turma daquela Corte, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 18 de maio de 2017. Pequenas contradições, referentes a aspectos periféricos da conduta, são inerentes ao psiquismo humano. Não têm o condão de minar a credibilidade do declarado pelos policiais, até mesmo porque não é crível a suposição de que agentes públicos que têm por dever funcional a manutenção da lei e da ordem viriam a juízo mentir (respondendo inclusive penalmente por sua conduta) para incriminar terceiro. Por outro lado: a) é de desprezível valor probatório o relato da informante Mariana, companheira do acusado, que tem total interesse em eximir seu consorte de sua responsabilidade penal e prestou declarações pouco críveis, na tentativa de fortalecer a tese de autodefesa; b) é irrelevante para o desfecho o depoimento da testemunha de defesa Thaís, que teria visto parcela ínfima dos fatos pela janela e de qualquer forma se limitou a dizer ter observado os policiais subindo as escadas, sem descartar, peremptoriamente, a possibilidade de o acusado ter subido as escadas, pouco antes disso (até porque não é crível que pessoa produtiva permaneça a observar escadas por tempo indeterminado). E nem se alegue nulidade do ingresso dos policiais no imóvel do acusado. Ao julgar o tema n.º 280, da repercussão geral (Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO, relator ministro Gilmar Mendes, julgado em 5 de novembro de 2015), o Supremo Tribunal Federal sedimentou, naquilo que importa neste momento, entendimento no sentido de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. Posto isso, na hipótese em julgamento, houve observância a referido precedente, porque ambos os policiais confirmaram ter seguido o réu, após este correr de um conhecido ponto de tráfico portando uma pochete, até a entrada do imóvel. E isto, por si, conferia fundadas razões concretas para o ingresso. Tanto assim que efetivamente foram localizadas porções de entorpecentes no local, também dentro da pochete que o réu trazia consigo. Soma-se a isso o som de descarga de vaso sanitário no interior do imóvel, logo após a perseguição do acusado, elemento indicativo da dispensa de drogas e apto a corroborar a legalidade da diligência. Afastadas quaisquer irregularidades durante a diligência, restou devidamente comprovada a prática de tráfico pelo réu. Não há, nesse contexto, espaço para a absolvição ou mesmo para a desclassificação da conduta. Passo, agora, à dosimetria da pena para o acusado, em atenção aos vetores específicos do artigo 42, da Lei de Drogas. Na hipótese em julgamento, o réu trazia consigo, no interior da pochete, 51 porções de cocaína, acondicionadas em pinos plásticos, 14 porções de crack, envoltos em papel alumínio, duas porções de maconha e cinco micropontos de “LSD”. A quantidade total de droga, pouco superior a 14 gramas líquidos (0,1 gramas de LSD, em 5 porções + 2,2 gramas de crack, em 14 porções + 3,0 gramas de maconha, em 2 porções e 9,3 gramas de cocaína, em 51 porções – 120/122), é tolerada sem exasperação de pena-base pelo que constitui a média da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tanto não procede a tese acusatória de que o encontro de pequena quantidade de cocaína (da qual o crack é derivado) justificaria a exasperação da pena-base que há precedente da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 503.848/MS, no seguinte sentido: “(...) 2. Ainda que considere nociva a natureza da droga apreendida, evidenciada a quantidade não relevante (32,93g de cocaína) e ausentes circunstâncias adicionais – inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, etc. –, não é razoável a exasperação da pena-base” (relator ministro Nefi Cordeiro, julgado em 27 de agosto de 2019). Posto isso, fixo a pena-base no piso legal: cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes e a incidência da atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal não pode conduzir a pena aquém do mínimo, nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Deve incidir, por outro lado, o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, porque não há prova de que o réu se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, não podendo a singela condenação constante de fls. 190 (ainda não transitada em julgado para a defesa) ser sopesada em desfavor do acusado, em razão do princípio da presunção da inocência e do entendimento sedimentado na Súmula n.º 444, do Superior Tribunal de Justiça. A redução deve ocorrer no percentual máximo de dois terços, que é aquele habitualmente utilizado pela média da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para situações como a presente, em que havia mercancia de pequena quantidade de droga, encontrada com réu menor de vinte e um anos. São penas finais do réu, assim: um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta seis dias-multa. Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, porque este é o regime legal aplicável à hipótese, considerada a quantidade de pena cominada. Revendo posicionamento anteriormente adotado sob enfoque pragmático, acabo por aderir ao que constitui entendimento hoje tranquilo do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a substituição da pena corporal na hipótese de tráfico privilegiado, que não é delito equiparado a hediondo. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por: a) prestação de serviços à comunidade por igual período ao da pena substituída; b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, quantia esta que deverá ser revertida para entidade pública ou particular com destinação social a ser indicada em sede de execução. Valor unitário do dia-multa no piso legal. Desnecessárias outras observações. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO INICIAL veiculada por meio desta AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra BRYAN WILLIAN IZIDORO, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, cumulado com o § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Por conseguinte, condeno-o: I) a cumprir a pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto. Substituo a pena privativa de liberdade por: a) prestação de serviços à comunidade por igual período ao da pena substituída; b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, quantia esta que deverá ser revertida para entidade pública ou particular com destinação social a ser indicada em sede de execução; II) ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, de valor unitário mínimo. Condeno o réu, ainda, ao pagamento da taxa judiciária, mas condiciono a exigibilidade desta verba ao sistema do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, porque ao acusado devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, diante da situação de miserabilidade constatada em seu interrogatório. Anote-se. A custódia cautelar se submete a juízo de proporcionalidade e não é proporcional a manutenção em cárcere daquele condenado a cumprir pena em regime aberto, com substituição. Por isso, concedo ao réu o benefício da liberdade provisória, independentemente de fiança, mas mediante: a) termo de comparecimento a todos os atos do processo; b) dever de manutenção de seu endereço atualizado nos autos; c) proibição de se ausentar da comarca em que reside por mais de oito dias, sem prévia autorização deste juízo. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Recurso em liberdade, mediante cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão ora cominadas. Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se esta decisão ao Tribunal Regional Eleitoral; b) expeça-se guia de execução definitiva; c) autorizo a destruição de eventual remanescente das substâncias apreendidas; d) expeça-se o necessário para a reversão do dinheiro e

dos celulares apreendidos em poder do acusado para o Fundo Nacional Antidrogas. Decreto o perdimento desses bens para o já aludido Fundo, com fundamento no artigo 63, I, da Lei de Drogas, por considerá-los vinculados à prática delitiva. Cumpridas as alíneas anteriores, arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Dispensado o registro (Provimento C.G. n.º 27/2016). Cumpra-se. Nada mais", saindo as partes intimadas. Em seguida, foi renovado o direito de entrevista privada entre o réu e seu advogado por meio da "sala virtual", com a garantia do sigilo da comunicação, permanecendo os demais em espera. Após a entrevista, houve o retorno deste servidor-organizador, do Magistrado e do representante do Ministério Público à audiência virtual. Pela

defesa e pelo sentenciado foi dito haver interesse em recorrer. Por fim, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos, etc. Recebo o recurso interposto pela defesa nesta data, saindo o defensor intimado para oferecer as razões no prazo legal, independente de nova intimação. Após, abra-se vista ao Ministério Público para as contrarrazões. Processado regularmente o recurso, cumpra-se o disposto nos Provimentos n.º 07/2007 e n.º 08/2011, remetendo-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens. Anote-se. Expeça-se guia de recolhimento provisória em nome do réu, remetendo-a regularmente instruída à Vara das Execuções Criminais competente". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do artigo 25, caput, da Resolução n.º 185/13, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça. Os presentes saem intimados. Nada mais. Eu, Douglas Beraldo, digitei.

MM. Juiz: (assinado digitalmente).